

1500544-39.2021.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA APARECIDA BUENO

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... o conheçam por passagens por tráfico (fls. 114/115).

Interrogado judicialmente, o acusado disse que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Contou que estava em poder da droga quando foi abordado pelos guardas e a droga se destinava ao tráfico. Contou que possui passagem por tráfico de drogas e que desde que saiu da prisão prometeu que não iria mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

1ª Vara

Praça Coronel Souza Ferreira, s/nº, . - centro

CEP: 13970-906 - Itapira - SP

Telefone: (19) 3863-0523 - E-mail: itapira1@tjsp.jus.br

1500544-39.2021.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500544-39.2021.8.26.0272

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE EDUARDO MOREIRA BEZERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA APARECIDA BUENO

Vistos.

FELIPE EDUARDO MOREIRA BEZERRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 15.06.2021, por volta das 15h15, na Rua Carmela Gali Papaleo, nº 05, Bairro Jardim Magali, nesta cidade e Comarca de Itapira, trazia consigo, para fins de tráfico, 7 (sete) porções de cocaína, na forma de crack, com peso aproximado de 2,0g (dois gramas), substância esta que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 08, auto de constatação preliminar de fl. 09 e laudo de exame químico toxicológico (fls. 81/83).

O acusado foi preso em flagrante no dia 15.06.2021 (fls. 01/05). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 37/40).

Notificado (fl. 70), o acusado apresentou defesa preliminar (fl. 87).

A denúncia foi recebida em 11.08.2021 (fls. 88/90) e o acusado foi citado (fl. 105).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o

acusado foi interrogado. Os depoimentos foram gravados em nuvem e disponibilizados às partes pelo Portal e-SAJ no sítio do TJSP na internet (fls. 114/115). Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se por memoriais. O Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 145/151), ao passo que a Defesa pugnou pela desclassificação para o crime de porte de drogas. Subsidiariamente, requereu, em caso de condenação, a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o reconhecimento da atenuante da confissão e a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 154/162).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/05), boletim de ocorrência policial (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fl. 08), auto de constatação preliminar (fl. 09), laudo toxicológico definitivo (fls. 81/83), croqui do local (fls. 134/140) e pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e se acha devidamente provada nos autos.

Com efeito, ouvido em juízo, o guarda municipal Antônio Sérgio Lemes narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo local em que há uma escada que liga a Rua China com a Rua Carmela Gali Papaleo, já conhecidas como ponto de tráfico de entorpecentes. Contou que foram conversar com o acusado e que o abordaram. Disse que o acusado admitiu que estava traficando entorpecente e colocou a mão dentro da bermuda, tirando a droga e a entregando voluntariamente. Contou, ademais, que também havia uma calça naquele mesmo local, que o acusado afirmou ser da propriedade dele. Nessa calça havia uma carteira no bolso contendo R\$40,00 (quarenta reais), em espécie. Por fim, disse que não conhecia o acusado dos meios policiais como traficante e não sabe dizer se os demais colegas de farda o conheciam (fls. 114/115).

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Paulo Borges, que, em juízo, ratificou a versão apresentada pela testemunha Antonio, salientando que o local dos fatos é conhecido como “escadão ao lado da casa do pão” e pela prática do tráfico de entorpecentes. Contou que foram abordar o acusado e que ele de pronto admitiu que estava traficando no local. Em seguida, o acusado enfiou a mão no bolso do shorts dele e entregou 7 pedras de crack. Disse que no local também havia um alambrado com uma caça jeans e o próprio acusado admitiu que pertencia a ele, com uma carteira no bolso, que, segundo ele, havia R\$40,00 (quarenta reais) em dinheiro proveniente do tráfico. Por fim, disse que não conhecia o acusado dos meios policiais e seus colegas, ao que parece, o conheciam por passagens por tráfico (fls. 114/115).

Interrogado judicialmente, o acusado disse que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Contou que estava em poder da droga quando foi abordado pelos guardas e a droga se destinava ao tráfico. Contou que possui passagem por tráfico de drogas e que desde que saiu da prisão prometeu que não iria mais traficar. Contudo, possui um problema sério com drogas. Devido a isso, voltou a usar drogas, perdeu o serviço e resolveu traficar novamente para sustentar seu vício. Acrescentou que está arrependido (fls. 114/115).

Como se vê, o acusado confessou a prática do crime em testilha e a sua confissão está em consonância com os depoimentos dos guarda municipais em juízo, plenamente coesos e harmônicos entre si, de modo a endossar a imputação feita na denúncia. Os depoimentos das autoridades policiais merecem credibilidade. Por ser tratarem de agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e devem ser acolhidas sem reserva, especialmente porque não foi demonstrado que tivessem algum especial interesse na incriminação da acusada.

Ademais, não é crível que servidores públicos que são, devidamente aprovados em concurso público, regularmente empossados e tecnicamente preparados para agirem de acordo com a lei, estivessem na posse de drogas para simular a existência de um delito e incriminar um inocente gratuitamente, de modo que seus depoimentos são imaculados e constituem meio idôneo de prova.

A propósito:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello). Com efeito, a partir das circunstâncias previstas no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, ora referidas e provadas, é possível concluir, com o necessário grau de certeza, que o acusado estava praticando tráfico de drogas. Dito de outro modo, as circunstâncias do caso não permitem admitir que as drogas encontradas com ele destinavam-se ao consumo pessoal.

As drogas apreendidas (7 porções de crack), o dinheiro apreendido e fruto da venda dos entorpecentes, a confissão do acusado e as demais circunstâncias em que se deram a prisão indicam, conclusivamente, que ele se dedicava à traficância. Em reforço a essa assertiva o fato de o acusado possuir condenação anterior por tráfico de drogas (cf. fls. 20/21).

Não é demasiado enfatizar, em consonância com o melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que, como no caso dos autos, o acusado estivesse simplesmente trazendo consigo as drogas para que reste caracterizado o crime, não se exigindo a prática de atos de mercancia para a sua configuração.

Neste sentido:

“Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido.” (RT 729/542).

“Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização”. (RT 714/357).

Inviável, por conseguinte, a desclassificação do delito para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

Vale anotar que, hoje em dia, é muito comum a prática de condutas caracterizadoras do crime de tráfico de drogas por usuários e viciados para sustentarem seus vícios. No entanto, isso não impede a responsabilização criminal dessas pessoas pela prática do tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP-HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael- RJTJSP 10/498)

“(…) Destaco ainda, que muito embora o acusada tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde: ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.” (REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Ressalto, por oportuno, o ensinamento de Fernando de Almeida Pedroso: “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf.

"Prova Penal", 2ª ed. RT, 2004, item 5, pág. 96).

A Defesa não logrou provar o contrário.

Assim, impõe-se a condenação do acusado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, não sendo possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, vez que ele é reincidente (fls. 20/21).

Finamente, reconheço a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, haja vista que a prática do delito se deu nas imediações de centro religioso, escola pública, praça esportiva, todos estes a menos de 65 metros de distância do local onde o tráfico de drogas era praticado, conforme, aliás, prova o croqui pericial de fls. 134/140.

Como se sabe, a referida causa de aumento tem caráter objetivo, bastando para sua incidência que o tráfico seja realizado nas proximidades dos locais ou estabelecimentos ali mencionados, sendo irrelevante o fato deles se encontrarem ou não abertos no exato momento em que se deu a apreensão das drogas, haja vista que a causa de aumento referida não está relacionada ao horário de funcionamento desses estabelecimentos, mas ao local, o que, sem dúvida alguma, facilita o acesso dos estudantes e também de outras pessoas à substância estupefaciente.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prática do delito de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimentos de ensino (art. 40, III, da Lei 11.343/06) enseja a aplicação da majorante, sendo despicienda a prova de que o ilícito visava atingir os frequentadores desse local. 2. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no Recurso Especial nº 1.558.551 MG (2015/0251830-1), 6ª Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, j. 12.09.2017).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1. CRIME COMETIDO PRÓXIMO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE DOIS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. QUANTUM DE AUMENTO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. 3. ORDEM DENEGADA. 1. Caso em que o Tribunal impetrado, acolhendo as alegações da acusação, reconheceu a causa especial de aumento da pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porque restou comprovado que a paciente comercializava droga nas proximidades de estabelecimento de ensino, razão pela qual majorou a reprimenda em 1/3 (um terço). 2. A constatação de que o tráfico de drogas era praticado nas imediações de estabelecimento de ensino torna dispensável a comprovação de que a paciente comercializava entorpecentes diretamente com os alunos da escola. Dessa forma, somente a partir de profunda dilação probatória os fundamentos deduzidos pelo Tribunal impetrado poderiam ser infirmados, medida incabível na via eleita, augusta por excelência. Precedentes. (...) 4. Habeas corpus denegado". (STJ, HC 201.788/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 09/02/2012)

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. DIMINUIÇÃO DA PENA. BENEFÍCIO NEGADO. INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 2. CRIME COMETIDO PRÓXIMO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A qualidade da droga apreendida, aliada ao fato de que, conforme estabelecido no acórdão, se dedicava o paciente a atividades criminosas, afastam a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. 2. A constatação de que o tráfico de drogas era praticado nas imediações de estabelecimento de ensino torna dispensável a comprovação de que o paciente comercializava entorpecentes diretamente com os alunos da escola. 3. Ordem denegada". (STJ, HC 121793/SP, 6ª Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 31/08/2011)

Assim, definida a responsabilidade do acusado, passo a dosar as penas aplicáveis. Na primeira fase da dosimetria, em observância ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas, que estabelece as circunstâncias judiciais preponderantes, anoto ser desfavorável a natureza do entorpecente apreendido (crack), de elevadíssimo grau destrutivo para as pessoas e para a sociedade. Por isso, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

A propósito:

"O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada." (STJ - HC n.º 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje. 15.03.2012).

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência, conforme faz prova a certidão de antecedentes criminais de fls. 20/21, que anota condenação anterior por tráfico ainda não atingida pelo prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal. Por serem equivalentes devem ser compensadas, permanecendo a pena intermediária inalterada. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição de pena. Por outro lado, verifica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. Assim, elevo a reprimenda em mais 1/6, tornando definitiva a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Como não há elementos sobre as condições econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Como se cuida de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), considerando o quanto da pena aplicada e a reincidência específica, impõe-se a fixação do regime fechado para o início da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º e 3º, do Código Penal, que reputo ser o mais adequado e suficiente ao caráter preventivo e repressivo da reprimenda.

Anoto, ainda, a impossibilidade de aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. A aplicação deste dispositivo carece de melhor regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento tão somente no tempo de custódia cautelar, o juízo do processo de conhecimento necessitaria ter acesso a dados pessoais da acusada, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui, além do requisito objetivo, o subjetivo. Tal análise, a meu ver, deve ser feita no âmbito da execução penal. Consigno que o desconto imposto pela legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas. Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo Juízo da Execução.

A propósito:

"E no tocante a aplicação do contido no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observa-se que detração de pena se trata de matéria cuja apreciação é de competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial, específica, não obstante relativamente recente reforma parcial do Estatuto Adjetivo tenha estabelecido a matéria no artigo em comento. Nem poderia ser diferente, uma vez que apenas o MM. Juiz das Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de condenações do embargante, aí incluídas todas as suas eventuais execuções, como também o seu histórico comportamental, na condição de detento" (TJSP, Embargos de declaração nº 0005822- 97.2007.826.0624/50000, rel. Des. Marco Antônio Cogan, J. 05/09/2013).

Inviável, ainda, a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, pois é medida insuficiente para a prevenção do abjeto comércio que se difunde e fomenta a delinquência no país. Pelas mesmas razões, também é incabível o "sursis", ainda

mais considerando a gravidade concreta da conduta do acusado, que estava traficando crack, de potencial devastador para o usuário, sua família e para a sociedade ordeira.

Finalmente, veda-se ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, sendo a prisão preventiva necessária para manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, máxime em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no caso concreto, muito especialmente para evitar a reiteração criminosa, máxime por conta de sua reincidência específica, que denota especial periculosidade.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado FELIPE EDUARDO MOREIRA BEZERRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, de valor unitário mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos das NSCGJ, recomende-se a prisão do acusado em presídio adequado ao regime prisional fixado nesta sentença. Expeça-se o necessário.

Como não houve controvérsia acerca da natureza e quantidade da droga apreendida, DETERMINO a sua destruição, caso já não tenha sido realizada, observadas as cautelas previstas nos arts. 50, §§ 4º e 5º, da Lei de Drogas.

DETERMINO, ainda, o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em poder do acusado, noticiado no auto de exibição e apreensão da fl. 08, por se tratar de provento do crime, conforme prescreve o art. 63, I, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, ficando autorizada a expedição de ofício à autoridade policial para que comprove o depósito judicial da referida importância, caso não haja essa informação nos autos. Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe e, oportunamente, guia de recolhimento provisória.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, ressalvada eventual inexigibilidade a ser aferida em sede de execução.

Se for o caso, expeça-se, oportunamente, certidão de honorários ao Defensor eventualmente nomeado ao acusado, nos termos da tabela do convênio entre a DPE/OAB. P.I.

Itapira, 18 de Janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA